

1502113-76.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... sua conduta, mas não fez menção a tráfico. Não sabe se o réu estava envolvido com tráfico, pois ele trabalhava na feira e respeitava a todos. Não presenciou quando os policiais chegaram e em quando localizaram a caixa mencionada. Disse que o acusado tem problemas psiquiátrico, pelo que recebe benefício do Estado. Os policiais disseram que era droga que havia dentro da caixa. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502113-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502113-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021583/2022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 22618422 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2021583 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS TOMAS MIQUELINO ASSARITO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

LUCAS TOMAS MIQUELINO ASSARITO e MARCOS PAULO DA CONCEIÇÃO ALVES, qualificados nos autos, foram denunciado e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca da capital, associaram-se entre si e com outros indivíduos não identificados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 15h, na Rua Novo Oriente do Piauí, nº

800, apartamento 13, Cangaíba, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 04 tijolos e 01 invólucro plástico contendo a substância Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 2,9 kg; em desacordo com autorização legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudo de constatação de fls. 27/31 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 203/205 (fls. 169/171).

Os réus foram presos em flagrante (fls. 01), sendo as prisões convertidas em preventivas (fls. 101/105).

A denúncia foi recebida (fls. 179/180). Os réus foram citados (fls. 206 e 207) e apresentaram resposta à acusação (fls. 173/174), sendo ratificado o recebimento da denúncia em audiência.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas, sendo, ao final, os réus interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação, condenando-se os réus por tráfico ilícito de entorpecentes. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição dos acusados e subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação da pena mínima e do redutor previsto no artigo 33, §4º da mesma lei.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do tráfico ilícito de entorpecentes foi demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, do laudo de constatação de fls. 27/31, do exame químico-toxicológico de fls. 203/205 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que também comprou a autoria delitiva.

O réu Lucas Tomas Miquelino Assarito negou a prática do delito. Alegou, em suma, que estava com Marcos Paulo fumando um baseado no estacionamento de seu prédio, quando Guilherme lhe entregou uma bolsa, mas não sabia que gavaí drogas em seu interior. Não sabe quem era essa pessoa, pois não o conhece. Guilherme pediu que guardasse a bolsa e aceitou porque tem problemas mentais. Não sabe se Guilherme mora perto e não o conhecia. Sua mãe quem disse que o nome dessa pessoa era Guilherme. Ela não estava presente no momento dos fatos, mas descobriu quem entregou a bolsa. Os vizinhos viram Guilherme lhe entregando a referida bolsa. Não sabe se há câmeras no estacionamento do prédio. Guardou a bolsa em sua casa, mas Marcos não subiu com ele para guardar bolsa. Policiais apareceram e os abordaram, perguntando onde era a casa de Marcos. Não contou para os policiais onde era sua casa tendo sido o porteiro quem a mostrou. Não disse para os policiais onde era sua casa porque havia o que havia na referida bolsa, a qual recebeu porque tem problemas mentais. Disse sofrer distúrbios, mas não sabe o que tem. As vezes, faz uso de gardenal. Não recebe benefício previdenciário (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O réu Marcos Paulo da Conceição Alves também negou a prática do delito. Alegou, em suma, que estava na casa de sua mãe e foi comprar uma porção de maconha. O ponto e na rua da casa de Lucas, O viu no estacionamento de seu prédio e foram fumar maconha juntos. Cerca de quinze minutos, entraram alguns carros, o que não estranhou, foi abordado por policiais. Indicaram onde moravam e na casa de Lucas. Os policiais entraram na casa de Lucas e apresentaram tabletes de maconha, dizendo que haviam encontrado no apartamento. Não os viu encontrando. Lucas disse que havia recebido uma sacola de um rapaz para guardar porque estava devendo um dinheiro para o mesmo. Não viu o rapaz entregando uma sacola para Lucas. Disse que Lucas não subiu sozinho até apartamento. Conhece Lucas há cerca de oito anos (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando suas versões com as demais provas do processo, conclui-se que não devem prosperar, eis que não encontram embasamento probatório. O policial civil Leandro Boendia Machado Salim afirmou, em síntese, que receberam

“denúncia anônima” de que ocorreria uma transação de entorpecentes no local, para onde se deslocaram. Identificaram dois indivíduos muito nervosos, so quais foram abordados. Um deles tinha uma pequena quantidade de maconha consigo, mas não se lembra qual deles. Os dois estavam parados no estacionamento e se mostrava nervosos. A pessoa que estava com a maconha acabou dizendo que havia mais dentro do apartamento. Não se lembra se a pessoa disse o destino da droga. Acompanharam os dois até o apartamento, onde encontraram mais quantidade maconha, acreditando ser cerca de quatro quilos, e mais um pó branco, não sabendo o que era, mas que não era cocaína. Disse que a entrada foi acompanhada por um vizinho. Afirmou que um dos réus levava consigo uma amostra do que seria transacionado. Firam os reis quem abriram a porta do apartamento. No se recorda se o vizinho estava já no momento da apreensão, mas acredita que tenha chegado logo depois. Não se lembra se havia balança, dinheiro ou cafeína. Ninguém comentou que Lucas era portador de problemas psiquiátricos, mas percebeu que um deles não estava bem. Não conhecia nenhum dos réus (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). Antônio Carlos de Oliveira, também policial civil, afirmou, em suma, que foram informados que haveria tráfico na porta do CDHU. Foram até o local, onde fizeram campana. Viram os réus conversando e olhando para os lados, como se estivessem aguardando alguém. Os abordaram, encontrando maconha no bolso de Marcos. Ele disse que estava aguardando uma pessoa que iria buscar a droga, mas não veio e indicou onde estava o resto das drogas, as quais guardavam para a pessoa de “Guinho”, segundo Lucas. Adentraram no apartamento por ele indicado, onde encontraram mais tijolos de maconha e balança de precisão. Não havia maconha com Lucas. Encontraram drogas na sala e na cozinha. Não se lembra qual deles residia naquele apartamento, mas ambos os levaram até o local (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A testemunha Jefferson Alex Dantas de Menezes afirmou, em suma, ser vizinho de Lucas e que é síndico do condomínio. Disse que, na data dos fatos, ouviu um barulho e percebeu que estava ocorrendo uma apreensão no prédio. Desceu para saber o que estava acontecendo e viu uma caixa na sala da casa de Lucas. Viu que havia um volume embalado em seu interior, mas não sabe o que era. Os acusados já estavam algemados. O pai do réu, uns dias antes, lhe pediu eu conversasse com o filho porque ele estava em uma “caminhada errada” achando estranha sua conduta, mas não fez menção a tráfico. Não sabe se o réu estava envolvido com tráfico, pois ele trabalhava na feira e respeitava a todos. Não presenciou quando os policiais chegaram e em quando localizaram a caixa mencionada. Disse que o acusado tem problemas psiquiátrico, pelo que recebe benefício do Estado. Os policiais disseram que era droga que havia dentro da caixa. No apartamento, estavam os acusados e os policiais (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Destarte, os depoimentos colhidos, além da quantidade e diversidade de drogas, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação do réu de que sua conduta se amolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

E há que destacar que não se vislumbra ilicitude na prova obtida com a busca e apreensão do entorpecente realizada na residência em questão, embora não comprovado que o réu consentiu o ingresso dos policiais em sua casa, pois a Constituição Federal no artigo 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade do domicílio, mas ressalva o ingresso, sem consentimento do morador, em caso de flagrante delito. Assim, observados os requisitos constitucionais, diante o flagrante de crime de tráfico no caso em tela, crime este de natureza permanente.

No caso em tela, pelo que se depreende dos autos, os policiais civis estavam investigando o local descrito na denúncia e encontraram drogas em poder dos acusados. Assim, presentes justa causa e urgência para o ingresso dos policiais no interior da residência, onde, aliás, encontraram expressiva quantidade de entorpecentes.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - Receptações e tráfico de drogas - Recurso defensivo -

Preliminar de violação ao princípio do juiz natural – Inocorrência – Designação prévia, dos magistrados, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça – Preliminar de nulidade ab initio, por violação a domicílio – Entrada franqueada – Tráfico de drogas – Delito permanente – Se aos policiais não foi dado o ingresso à residência, havia permissão constitucional para a penetração, porquanto o delito permanente tem sua consumação protraída no tempo – Preliminares afastadas – No mérito, materialidades e autorias todas comprovadas – Ciência da origem ilícita dos bens que se comprova pela atitude e natureza da res – Tráfico mais que evidenciado – Elevadíssima quantidade de entorpecente, com petrechos para venda – Pena não modificada, para o tráfico, em virtude de erroneamente se ter aplicado a causa de diminuição especial, para indivíduo dedicado às atividades criminosas – Preliminares afastadas e recursos não providos. (TJ-SP - APL: 00442611420148260114 SP 0044261-14.2014.8.26.0114, Relator: Alberto Anderson Filho, Data de Julgamento: 28/07/2016, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/08/2016) (grifo nosso)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio não configurada. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada – Rejeição. MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade de droga (03 tijolos de maconha, com peso líquido de 684,60 gramas), além de dinheiro e uma balança de precisão – Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Quantidade e natureza do entorpecente e mau antecedente (1/6) – Compensação da agravante do artigo 61, II, j, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública) com a atenuante da confissão espontânea. Reincidência específica (1/6) – Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Prequestionamento – Apelo desprovido (TJ-SP - APR: 15018282120208260530 SP 1501828-21.2020.8.26.0530, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 23/04/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021) (grifo nosso)

Destarte, não se verifica, no caso em tela, desrespeito ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que, apreciando o tema 280 da repercussão geral, por maioria, fixou tese nos seguintes termos:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. Conquanto os acusados tenham tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não se verifica veracidade em tais declarações, pois estes não relataram qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas arroladas pela acusação tivessem algum motivo para lhes incriminar falsamente.

Ademais, não se verifica verossimilhança nas alegações dos acusados, eis que não trouxeram qualquer testemunha que comprovasse que Guilherme teria entregado a bolsa para Lucas, embora este tenha dito que o ato fora presenciado por diversos vizinhos.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, “guardar” e “ter em depósito”, para fins de tráfico, 04 tijolos e 01 invólucro plástico contendo a substância Tetrahydrocannabinol, conhecida como

“maconha”, com peso líquido de 2,9 kg.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/05 restando provada a materialidade delitiva (laudo toxicológico) e a autoria.

Todavia, não há provas seguras de que os réus se associaram para o fim de tráfico, sendo que para caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, não basta o concurso de agentes, pois o tipo penal fala “associarem-se”, o que requer estabilidade, ainda que não cheguem os associados à prática efetiva de algum tráfico e ainda que não o façam de forma reiterada. No caso em tela, demonstrado o concurso de agentes, mas não se evidenciou uma união, um vínculo estável e duradouro entre os réus.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de tipicidade, ilicitude ou de culpabilidade, a condenação dos réus por tráfico ilícito de entorpecentes é medida que se impõe. Em relação a primeira, cumpre asseverar embora Lucas afirme ser portador de doença mental, não foi trazido qualquer elemento que servisse como início de prova para que se amparasse a instauração de incidente de insanidade mental. Assim, nada há, nos autos, que permita concluir pela ausência ou redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Passo à dosimetria da pena:

Quanto ao réu LUCAS TOMAS MIQUELINO ASSARITO:

Na primeira fase, verifica a expressiva a quantidade de droga apreendida. Assim, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal: em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes e nem atenuantes. Assim, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo a uma entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Quanto ao réu MARCOS PAULO DA CONCEIÇÃO ALVES:

Na primeira fase, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 98/100, proc. 0046199-81.2010.8.26.0050, 9ª Vara Criminal de São Paulo). Ademais, verifica a expressiva a quantidade de droga apreendida. Assim, fixo a pena-base em 1/4 acima de seu mínimo legal: em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal (fls. 98/100, proc. 0062731-86.2017.8.26.0050, 31ª Vara

Criminal, e proc. 0093150-94.2014.8.26.0050, 10ª Vara Criminal de São Paulo). Ausentes atenuantes. Assim, majoro a pena em 1/6, que passa a ser fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes.

Em face da reincidência do acusado e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, (art. 33, §§2º e 3º do CP). Não obstante o tempo da prisão cautelar, deixo de ficar regime semiaberto, pois não decorrido o prazo exigido pelo artigo 112 da LEP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu:

LUCAS TOMAS MIQUELINO ASSARITO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço à comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

MARCOS PAULO DA CONCEIÇÃO ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Concedo ao réu Lucas o direito de recorrer em liberdade, diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

No entanto, não concedo ao réu Marcos o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a manutenção da prisão cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, eis que acusado é reincidente e portador de maus antecedentes. Recomende-se ao cárcere em que se encontra. Havendo habeas corpus pendente de julgamento, encaminhe-se cópia deste sentença ao E. Tribunal de Justiça para instrução do writ.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA